

AÇÃO PENAL 650 SANTA CATARINA

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
REVISOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
ADV.(A/S) : RODRIGO MEYER BORNHOLDT
ADV.(A/S) : CARLOS ADAUTO VIRMOND VIEIRA

DECISÃO

AÇÃO PENAL. SENADOR DA REPÚBLICA. CRIMES DE PREVARICAÇÃO E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DENUNCIADO COM MAIS DE 70 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DETERMINADO.

Relatório

1. Ação Penal instaurada no Superior Tribunal de Justiça contra LUÍZ HENRIQUE DA SILVEIRA, quando no exercício do cargo de Governador de Santa Catarina, BRÁULIO CÉSAR DA ROCHA BARBOSA e MAX ROBERTO BORNHOLDT, para apurar alegada prática dos crimes de prevaricação (art. 319 do CP) e patrocínio de interesse privado perante a administração fazendária (art. 3º, inc. III, da Lei 8.137/90), nos termos seguintes:

*“(...) Os fatos narrados constam dos autos do **Processo Administrativo n.º 1.00.000.006593/2004-02 — MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL — PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA (Autuado em 28/07/2004 — 15:17)**, iniciado Ofício n.º 130/13’ PJ (fl. 01), pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com as peças da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o Estado de Santa Catarina, juntando entre outros um CD, da gravação da Entrevista do*

AP 650 / SC

Chefe do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, em programa da Rede SC Notícias do Sistema Brasileiro de Televisão, no dia 1º de junho de 2004, revelando seu descontentamento com a atuação do fiscais na Cidade de Joinville.

Na espécie, 2 (dois) são os fatos:

*1 — o **Decreto n.º 1.894/2004 (11. 29)** que, alterando o art. 69 do Dec. N.º 2870, de 27/8/2001 (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Santa Catarina — RICMS / SC) — determina — **no art. 69 — A - a necessidade de prévia autorização do Secretário de Estado da Fazenda para a fiscalização das empresas enquadradas no regime normal; quanto à fiscalização das empresas enquadradas no Tratamento Diferenciado e Simplificado de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (SIMPLES/SC), a fixação do caráter orientativo (prioritariamente), exceto — quando se tratar de infrações instantâneas detectadas em fiscalização de trânsito — estando assinado: pelo Governador, Sr. LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, pelo Secretário de Estado da Casa Civil, Sr. BRÁULTO CÉSAR DA ROCHA, e pelo Secretário de Estado da Fazenda, Sr. MAX ROBERTO BORNHOLDT.***

*2 — a **Portaria SEF n.º 136 / 2004, de 1º/06/2004 (fls. 30/33)**, que dispõe sobre o planejamento das atividades de fiscalização — regulamentando os §§1º e 30 do art. 69 — A do RICMS — SC/01 (11s. 30/33) — assinada pelo Secretário de Estado Fazenda, Sr. MAX ROBERTO BORNHOLDT.*

A Ação Civil Pública referida nos autos é a de n.º 038.04.038680-2, ajuizada na Vara da Fazenda Pública de Joinville, com o último andamento em 23/07/2004, contando "Aguardando Outros — Vencimento: 30/07/2004 — aguardando carta precatória".

(...)

Baixado o Decreto n.º 1.894, de 31 de maio de 2004, pelo Governador de Santa Catarina, Sr. LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, sendo referendado pelo Secretário de Estado da Casa Civil, Sr. BRÁULIO CESAR DA ROCHA BARBOSA e pelo Secretário de

AP 650 / SC

Decreto citado, integram a presente Denúncia como co-autores (art. 29, do CP).

O Sr. MAX ROBERTO BORNHOLDT, como Secretário de Estado da Fazenda, baixou a Portaria SEF n.º 136/04, para regulamentar o Decreto n.º 1.894/2004, disciplinando o planejamento das atividades de fiscalização. Com a sua conduta, reiterou o Denunciado MAX ROBERTO BORNHOLDT conduta anterior — devendo, pois sofre duplo enquadramento.

A conduta dos Denunciados afronta os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade. Pela leitura de tais atos administrativos evidencia-se restringido o exercício da atividade de fiscalização tributária. Admitida a adoção de critérios de oportunidade e conveniência. Não há poder discricionário a ser admitido na espécie.

Assim, enquadram-se as condutas acima narradas no disposto no art. 319, do CP (cf. o art. 3º, caput, da Lei n.º 8.137/90).

(...)

V

DO PEDIDO

Considerando os fatos narrados e o direito aplicável à espécie, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia:

1 — LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, como incurso no art. 319, do Código Penal, e no art. 3.º, inciso III, da Lei n.º 8.137/90;

2 - BRÁULIO CÉSAR DA ROCHA BARBOSA, como incurso no art. 319, do Código Penal, e no art. 3.º, inciso III, da Lei n.º 8.137/90, e;

3 - MAX ROBERTO BORNHOLDT, como incurso no art. 319, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 3.º, inciso III, da Lei n.º 8.137/90;

Requerendo o Ministério Público sejam efeitos da condenação perda do cargo, ou da função pública — art. 92, I, a, do CP — para o Governador e para Co-réus” (fls. 2-16, destaques do original).

2. Em 22/04/2005, o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o andamento da ação penal e o curso do prazo prescricional, desde 09/11/2004, e determinou o

AP 650 / SC

desmembramento do processo, permanecendo naquele Tribunal Superior apenas o réu com prerrogativa de foro (fl. 174/175).

3. Em 16/05/2011, os autos vieram a este Supremo Tribunal Federal, porque o investigado assumira o cargo de Senador da República (fls. 343 e 346).

4. Em 03/10/2011, determinei a notificação do acusado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 (fl. 354).

5. Em 06/02/2012, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 392/413).

Examinada a matéria posta à apreciação, **DECIDO**.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal, porque evidenciada a prescrição da pretensão punitiva estatal, “*matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício, inclusive (CPP, art. 654, §2º)*” (AI 600500 AgR-ED/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 09/12/2013).

7. Na linha da jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal, verificada a prescrição da pretensão punitiva “*há de o juiz proferir ... para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo*” (Inquérito n. 1.604-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002).

Nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas na Ação Penal n. 443, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 24.10.2007, nas Petições ns. 3.641, de minha relatoria, DJ 1º.8.2006, 4.548, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 18.8.2009, 3.590, Relator o Ministro Gilmar Mendes e nos

AP 650 / SC

Inquéritos ns. 2.806, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ 30.6.2009, 2.654, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 7.4.2008, 2.093, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 24.3.2004 e 1.950, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 30.3.2006, neste último se anotando:

“(...) DECISÃO: Extrato da denúncia (f. 134/138):

‘O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (...) vem, perante esse Colendo Supremo Tribunal Federal, oferecer DENÚNCIA em desfavor...

1. Consta do referido procedimento investigatório que no dia 03 de março de 2002, por volta das 18 horas, na sala 1 do Aeroporto de Congonhas, São Paulo-SP, foi detectada pela fiscalização de raio x a existência de grande quantidade de dinheiro, em espécie, na bagagem de mão do ora denunciado, que embarcava no voo 3230 da TAM com destino a Belo Horizonte-MG.

(...)

5. As provas coligidas demonstram a total improcedência das manifestações do ora denunciado juntadas aos autos.

6. Ao utilizar expressões desprestigiadoras e humilhantes dirigidas a funcionários públicos no exercício de suas funções, com o propósito de menosprezá-los, é de se concluir que o denunciado incorreu no crime de desacato, previsto no art. 331 do CP.

(...)

8. Dessume-se, portanto, que o denunciado, agindo com vontade livre e consciente de menosprezar e humilhar, dirigida à produção do resultado criminoso, desacatou policiais federais no exercício regular de suas funções. Está, pois, incurso nas penas do art. 331 do Código Penal.

(...)

Considerando-se os efeitos de coisa julgada material, o arquivamento com fundamento na extinção da punibilidade pela prescrição há de ser objeto de decisão do órgão judicial competente (Inq 1.538 - QO, Pleno, Pertence, DJ 14.9.01).

Os fatos, segundo a denúncia, ocorreram em ‘03 de março de 2002’, sem que houvesse, desde então, qualquer causa interruptiva da prescrição que, hoje - transcorridos mais 4 anos -, já se operou (C.

AP 650 / SC

Penal, arts. 10; 107, IV; 109, V; 114, II; e 331).

Assim - no uso do poder que confere ao relator o art. 3º, II, da L. 8.038/90 -, julgo extinta a punibilidade do fato pela prescrição da pretensão punitiva (L. 8.038/90, art. 3º, II).

Arquive-se (...)".

8. O crime de prevaricação (CP, art. 319) imputado ao denunciado teria ocorrido em 31.05.2004 e o crime de patrocínio de interesse privado perante a administração fazendária (art. 3º, inc. III, da Lei 8.137/90) teria ocorrido em 1º.6.2004.

9. A pena máxima estabelecida para o crime de prevaricação é de **um ano de detenção** (Art. 319 - *Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa*). A pena máxima prevista legalmente para o crime do art. 3º, inc. III, da Lei n. 8.137/90 é de **quatro anos de reclusão** (Art. 3º *Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal (Título XI, Capítulo I): (...) III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa*).

10. A prescrição da pretensão punitiva estatal do crime mais grave é 8 (oito) anos, consoante artigo 109, inc. IV, do Código Penal (Art. 109. *A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro*).

11. Consta do sítio do Senado Federal (www.senado.gov.br) ter o denunciado nascido em 25.2.1940, contando, atualmente, mais de setenta anos de idade. Incide, na espécie, a regra prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se pela metade o lapso prescricional do crime mais

AP 650 / SC

grave, que passa a ser de **quatro anos**.

12. De se observar, ainda, ter o denunciado exercido, duas vezes, mandato de Governador do Estado de Santa Catarina (períodos de 2003.2007 e 2007.2011).

13. Nos termos das decisões de fls. 174/175 e 264/267, o prazo prescricional permaneceu suspenso entre a data do recebimento do ofício, encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça, solicitando licença à Assembléia Legislativa para a instauração do processo-crime em desfavor do denunciado, e a data de sua renúncia ao mandato eletivo (Inqs. ns. 2179-MG, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 13.12.2004 e 3101-PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 26.8.2011),

14. O lapso prescricional do crime mais grave iniciou-se na data dos fatos (1º.6.2004), sendo suspenso em 9.11.2004 (fl. 167), data do recebimento, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do primeiro pedido de permissão para processar e julgar a acusação contra o então Governador, tendo transcorrido, no período, o prazo de **cinco meses e oito dias**.

15. Em 6.7.2006, o denunciado renunciou ao mandato de Governador do Estado, retomando-se a contagem do prazo de prescrição até 8.2.2007 (fls. 262) quando foi recebido, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o segundo pedido de autorização, para instaurar processo-crime contra o denunciado, reeleito Governador daquele Estado, tendo transcorrido, nesse período, o lapso prescricional de **sete meses e dois dias**.

16. Em 25.3.2010 (fls. 276), o denunciado renunciou, novamente, ao cargo de Governador de Santa Catarina, retomando-se o lapso prescricional que, desde então, não foi mais suspenso ou interrompido, tendo transcorrido **quatro anos, oito meses e treze dias** até a presente

AP 650 / SC

data.

17. Assim, desde a data do crime mais grave (1º/06/2004) até o presente momento, excluindo-se os períodos de suspensão do prazo prescricional (9.11.2004 até 6.7.2004 e 8.2.2007 até 25.3.2010) transcorreu prazo superior a cinco anos, sete meses e 23 dias, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, que operada em **15/03/2013**.

18. Pelo exposto, **reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva e declaro extinta a punibilidade do denunciado LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA**, pelos fatos narrados na denúncia, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, inc. III e 115 do Código Penal, além do art. 3º, inc. II, da Lei n. 8.038/90 c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, §4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Após o trânsito, **arquive-se.**

Brasília, 7 de novembro de 2014.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA**
Relatora